논술

2

제시된 <조건>에 따라 <사례>를 논평하시오. (900 ~ 1200자, 50점)

2020학년도 법학적성시험

1

제 3 교시

논 술

성명	

수험 번호							

<조건>

1. 아래 <관점> 중에서 하나를 선택하고, 다른 <관점>을 모두 반박할 것

2. 각 <사례>에 나타난 쟁점을 발견하고, 선택한 <관점>에 따라 각 <사례>의 법적 판단을 평가할 것

3. <관점>을 활용할 때는 ㉮, ㉯, ㉰와 같은 방식으로 표시할 것

<사례>

<사례 1>

중세 말 X국은 최고 법전인 치국대전(治國大典)에서 형법의 개정을 금지하고, 대신 형법전에 '마땅히 처벌할 만한 행위에는 유사한 조문을 적용할 수 있다'는 원칙을 규정하고 있었다. X국 사람인 甲은 화약을 사사로이 제조하여 화적떼에게 팔아넘기려다 발각되었다. X국의 형법전에는 사인(私人)이 화약을 제조하는 행위를 처벌하는 조문이 없었다. X국 병기창이 화약 제조에 관한 신기술을 외국에서 수입하였던 까닭에 개인이 화약을 밀조하는 상황을 형법은 예상하지 못했던 것이다. 법원은 논의 끝에 형법전 상 동전 또는 달력 위조죄를 이 사건에 적용하기로 하였다. X국에서 동전의 주조나 달력의 제작은 국가가 독점해 왔다. 경제적 신용 수단으로서 화폐의 공급은 국가의 전권에 속하기 때문에 조폐창에서 동전의 주조를 전담하도록 하였고, 달력은 농사 일정에 관련되어 정확한 정보가 요구되기 때문에 일기청에서만 제작하도록 하였다. 법원은 화약을 사사로이 제조하는 행위를 동전 또는 달력의 위조와 같이 국가의 전권에 도전하는 행위로 보고 甲에게 유죄를 선고하였다.

<사례 2>

Y국 사람인 乙은 돈을 걸고 전통적인 카드 게임을 하다가 종교법 위반으로 체포되었다. Y국의 헌법에 의하면 법원은 종교법 사건에서 종교법 위원회의 판단을 따르도록 되어 있다. Y국 종교법에는 '화살 던지기 내기'만 명시적으로 금지되어 있었다. 화살 던지기는 일곱 걸음 거리에서 통에 화살을 던져 넣어 승패를 결정하는 게임을 의미한다. 그러나 당시 널리 알려진 도박 행위의 하나였던 화살 던지기 내기는 세월이 흐르면서 도박의 대명사가 되었다. 乙은 종교법이 금지하는 내기는 화살 던지기뿐이므로 카드 게임은 여기에 해당하지 않는다고 항의하였다. 또한 카드 게임의 승패는 화살 던지기와 달리 실력과 훈련에 따라 결정된다고 주장하였다. 법제정 당시의 기록을 검토한 종교법 위원회는 종교법이 내기를 금지한 이유가 불필요한 금전적 손실의 위험으로부터 사람을 보호하는 데에 있으며, 따라서 그러한 위험이 있는 모든 내기는 금지된다고 판단하였다. 법원은 이러한 판단에 따라 乙에게 유죄를 선고하였다.

<관점>

<관점 ㉮>

입법자가 모든 사례를 고려할 수는 없어. 처음부터 완벽한 법이란 존재하기 어려워. 그런 까닭에 다양한 역사적 자료나 유사한 입법례를 통해 입법자의 본래 의도를 발견해서 법을 해석하고 적용하는 것이 옳다고 생각해.

<관점 ㉮>

법의 해석과 적용에 있어서는 언어의 사전적(辭典的) 의미가 가장 중요해. 사람들은 통상 그런 의미로 법을 이해하거든. 그런 점에서 언어의 객관적인 의미에 따라 법을 해석하고 적용하는 것이 옳다고 생각해.

<관점 ㉯>

사회적 상황이나 판단은 변할 수 있기 때문에 법을 사전적 의미로 한정하는 것은 지나치게 좁은 해석이야. 그리고 법의 제정 시점보다 법의 적용 시점에서 합당한 것으로 수용된 견해에 따라 법을 해석하고 적용하는 것이 옳다고 생각해.

<사례>에서 나타난 문제점을 분석하고 <규제 형식> 중 하나를 선택하여 <조건>에 따라 <사례>를 해결하시오. (900 ~ 1200자, 50점)

<조건>

1. 자신이 선택한 <규제 형식>을 두 <사례>에 일관되게 적용할 것

2. 자신이 선택하지 않은 <규제 형식>을 반박할 것

3. <규제 지침> 을 활용하여 논변할 것

4. <규제 지침> 을 활용할 때는 ㉮, ㉯, ㉰와 같은 방식으로 표시할 것

<사례>

<사례 1>

최근 개나 고양이 이외에도 파충류나 야생 포유류 등 다양한 동물을 키우는 사람이 늘고 있다. 그러나 관련 법은 국제적 멸종 위기종에 해당하는 동물을 개인이 키우는 것을 금지할 뿐 그 밖의 동물을 개인이 키우거나 거래하는 것에 별도의 규제를 마련하고 있지 않다. 이로 인해 멸종 위기종에 해당하지 않는 뱀, 거북이, 악어, 북극여우 등과 같은 야생동물이 인터넷에서 제한 없이 거래되고 있다. 이에 동물 보호 단체 P는 충분한 정보나 지식 없이 개인이 야생동물을 키우게 되면 공중 보건 위해, 질병 및 상해 위험, 생태계 위협 등 각종 문제가 발생할 수 있을 뿐만 아니라, 해당 동물의 건강과 복지에도 나쁜 영향을 미칠 수 있다고 경고한다. 실제로 외국에서는 키우던 뱀의 공격을 받아 사망한 사고도 있었음을 강조한다. P는 보건 당국이 지정한 동물만을 개인이 반려 동물로 키울 수 있도록 법으로 규제해야 한다고 주장한다.

<사례 2>

스타트업(start-up) 기업 Q는 이용자가 현재 있는 곳에서 가까운 주차장의 위치와 주차 요금을 알려 주는 주차 공유 서비스 사업을 시작하려 한다. 서비스의 핵심 기능은 현재 활용되지 않는 주차 공간을 다른 사람이 쓸 수 있게 함으로써 도심지의 주차난을 해소하려는 것이다. Q는 사업을 위해 관할 지방자치단체에 사업허가를 신청하였다. 그러나 담당 공무원은 관련 법에는 주차 공유를 금지하는 규정도 없지만 이를 허용하는 규정도 없으므로 기존의 조례를 개정하여 법령상 근거를 마련하지 않는 한 사업을 허가해 줄 수 없다고 하였다. 이에 Q는 사업의 신속한 시행을 위해 관할 지방자치단체에 조례의 개정을 여러 차례 요구하였지만 수년 동안 개정 작업은 진척되지 않고 있다. Q는 스타트업 기업이 새로운 상품이나 서비스를 개발해도 각종 규제 때문에 신속하게 시장에 진출하는 데 어려움을 겪고 있다고 토로한다.

<규제 형식>

(1)포지티브 규제(positive regulation):허용되는 것만을 규정하고 나머지는 원칙적으로 금지하는 규제 형식

(2)네거티브 규제(negative regulation):금지되는 것만을 규정하고 나머지는 원칙적으로 허용하는 규제 형식

* 확인 사항

○문제지와 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확하게 기재하고 표기했는지 확인하십시오.
○답안의 분량 미달과 분량 초과는 같은 기준으로 감점됩니다.

<규제 지침>

㉮ 규제는 사회가 요구하는 바를 정확하게 포착하여 이에 응답해야 한다.

㉯ 규제는 인간의 자유와 권리를 최대한 보장하는 데 역점을 두어야 한다.

㉰ 규제는 행위를 제한하는 것을 넘어 특정한 정책이나 가치를 형성하고 조정해야 한다.

㉮ 규제는 사회 및 시장이 스스로 문제를 해결할 수 있으므로 가능한 한 적게 해야 한다.

㉯ 규제는 인간과 자연의 지속 가능한 공존을 추구해야 한다.

㉰ 규제는 사회의 공리를 극대화하는 데 이바지해야 한다.

㉱ 규제는 사회에 해악이 되는 행위를 예방하고 금지해야 한다.